

Resumen Largo

Aspectos Legales

El Concepto de Derecho	2
Estructura Constitucional	8
Hechos y Actos Jurídicos	13
Contratos	17
Contratos Informáticos	21
Derechos Intelectuales	27
Voto Electrónico	31

El Concepto de Derecho

El texto comienza señalando la controversia inherente a la definición de Derecho, que varía según la postura iusfilosófica adoptada. Se presentan tres definiciones destacadas:

Según Bidart Campos, el derecho es "la realidad compuesta por conductas humanas en relación de alteridad social".

Para Borda, es un "...conjunto de normas de conducta humana obligatorias y conformes con la justicia".

Kelsen lo define como "...Un orden coactivo, como un sistema de normas que prescriben o permiten actos coactivos bajo la forma de sanciones socialmente organizadas".

Se plantea la pregunta fundamental sobre si estas definiciones buscan comprender un fenómeno jurídico específico (como el derecho argentino) o aprehender las características comunes a todos los ordenamientos. Se subraya que las discusiones sobre la realidad del derecho a menudo esconden concepciones no expresadas sobre la validez del derecho derivada de una idea anterior de carácter inmanente. Esta idea previa se convierte en el estándar con el que se compara un conjunto de normas para considerarlo Derecho.

El texto introduce el concepto de "definición persuasiva", utilizado por autores como Alf Ross. Estas definiciones, como las presentadas al inicio, necesariamente incluyen una toma de posición del estudioso que influye en el interlocutor. Se argumenta que una mera descripción del objeto no debería impedir su calificación valorativa autónoma. Se ejemplifica con la posibilidad de admitir el contrato de compraventa de esclavos como derecho sin que ello implique apoyo a la institución.

Frente a la complejidad de una definición abstracta, se propone una definición más simple y útil al restringirse a un ordenamiento determinado. Así, se define el ordenamiento jurídico como "el conjunto organizado de normas emanadas de un poder estatal competente, las cuales son percibidas por la población como obligatorias".

Se analizan los componentes de esta definición:

Conjunto organizado de normas: Implica una jerarquía que permite definir la ley aplicable en un caso concreto. Principios como la supremacía constitucional o la ley

penal más benigna son ejemplos de cómo se resuelve el conflicto de leyes. Esto permite a los sujetos de derecho anticipar las consecuencias legales de sus actos. Emanadas de un poder estatal competente: Toda norma se basa en la existencia de un Estado que la crea y vela por su cumplimiento. Incluso cuando las normas parecen emanar de particulares, es el Estado quien las reconoce y les otorga efectos jurídicos (ej. art. 1197 Cód. Civil). La competencia del organismo emisor es crucial, ya que una norma dictada por un organismo incompetente carece de efecto.

Las cuales son percibidas por la población como obligatorias: El ordenamiento jurídico debe contemplar mecanismos de corrección o castigo para el apartamiento de las conductas prescritas. La coerción es una parte necesaria. Hans Kelsen sostiene que la sanción es la nota definitoria de una norma jurídica, definiéndola como "un acto coactivo que consiste en la privación, forzada si es necesario, de bienes tales como la vida, la libertad o cualquier otro valor, tenga o no contenido económico". Esta característica se relaciona directamente con el carácter estatal del ordenamiento y el monopolio de la fuerza por parte del Estado, prohibiendo la justicia por mano propia.

2. Derecho Objetivo y Subjetivo

La palabra "derecho" se usa en un doble sentido:

Derecho Objetivo, Positivo o Vigente: Se refiere al conjunto organizado de normas vigentes de un país. Tiene un carácter general y no especifica situaciones particulares.

Derecho Subjetivo: Refiere a los efectos que el ordenamiento jurídico tiene sobre los particulares. Se define como "la facultad legal de exigir a otra persona una determinada conducta".

Ambos conceptos están estrechamente relacionados. El derecho subjetivo es la consecuencia y el aspecto dinámico del derecho objetivo. Mientras el objetivo es una enunciación estática, el subjetivo es su aplicación a una situación determinada, permitiendo la efectividad de la ley.

Se mencionan las teorías clásicas sobre la naturaleza del derecho subjetivo, que lo ven como un reconocimiento de una voluntad por parte del derecho. Esta visión es criticada por su carácter absoluto, que podría validar actos abusivos.

Se destaca la contribución de Von Ihering en el siglo XIX, quien sostuvo que el derecho subjetivo constituye "...un interés jurídicamente tutelado". Este enfoque limita el ejercicio de un derecho al interés que motivó su consagración, dando pie a la doctrina del ejercicio abusivo de un derecho.

También se presenta la postura de Kelsen, quien niega la existencia del derecho subjetivo en el sentido tradicional. Para él, los sujetos son titulares de obligaciones impuestas en beneficio de un tercero. Lo que la doctrina tradicional llama derecho es, para Kelsen, el cumplimiento de un deber por parte del obligado.

Más allá de las discusiones filosóficas, el derecho subjetivo cumple funciones importantes, siendo la principal la idea de una titularidad de derecho. Esto es fundamental en el derecho procesal para definir quién puede reclamar la ejecución forzada de un derecho (concepto conocido como legitimación activa).

3. El Derecho Objetivo: Sus Divisiones

Aunque el ordenamiento jurídico es un sistema único, la ciencia jurídica lo divide en ramas para su estudio, aunque estas divisiones son arbitrarias y los problemas jurídicos a menudo involucran varias ramas. Los criterios clasificatorios principales son:

Derecho de Forma y Fondo o Sustancial:

Fondo o Sustancial: Definen derechos o relaciones jurídicas entre las partes.

Procedimiento o Forma: Regulan los procedimientos ante la autoridad competente en caso de disputa de derechos. Esta distinción es importante en Argentina por la facultad delegada de las provincias a la Nación para legislar el derecho de fondo.

Derecho Público y Derecho Privado:

Derecho Público: Originalmente definido por la relación de subordinación del individuo respecto del Estado. Sin embargo, esta definición no abarca el Derecho Internacional Público. Se aclara que la sola presencia del Estado no determina el derecho público; el Estado debe estar cumpliendo su función de poder público (actividades esenciales para el desarrollo social como justicia, seguridad, educación), a diferencia de su accionar como persona de derecho privado.

Ramas del Derecho Público mencionadas: Derecho Constitucional (estudio del texto constitucional y la estructura del poder del Estado), Derecho Penal (regula el poder punitivo del Estado), Derecho Internacional Público (rige relaciones entre Estados soberanos), Derecho Administrativo (regula funcionamiento de la administración pública y sus relaciones con particulares).

Derecho Privado: Clásicamente, carece de la nota de orden público. Las relaciones se establecen entre partes en igualdad de condiciones y los bienes jurídicos protegidos son más económicos que sociales. En la actualidad, la introducción de elementos del derecho público ha llevado a limitar conceptos como la propiedad y la igualdad formal de las partes para evitar abusos de posiciones dominantes.

Ramas del Derecho Privado mencionadas: Derecho Civil (la rama más antigua, que rige las relaciones jurídicas de los sujetos en su condición de tales, independientemente de su actividad), Derecho Comercial (regula la estructura de la empresa, relaciones de comerciantes y actos de comercio), Derecho Laboral (norma relaciones derivadas del contrato de trabajo; aunque históricamente se ubica en el derecho privado, presenta elementos de orden público y intervención estatal, considerándose una figura mixta).

4. Las Fuentes del Derecho

El término "fuentes del derecho" se utiliza en varios sentidos:

Sentido Filosófico: Refiere a los antecedentes ideológicos para la redacción de la ley (ej. invocación a Dios en el preámbulo de la Constitución).

Sentido Histórico: Constituyen los antecedentes legales, sociales o políticos que dan lugar a la creación de una norma (ej. pactos preexistentes, antecedentes constitucionales de EE. UU. para la Constitución Nacional).

Sentido Jurídico: Denotan los fenómenos jurídicos que originan derechos y obligaciones en los sujetos del ordenamiento. Este es el sentido de interés en el texto. Se destacan las siguientes fuentes:

La Ley: En sistemas continentales como el argentino, es la fuente fundamental y primera. Su preponderancia es clara, y las demás fuentes a menudo dependen de que la ley las recepcione expresamente.

Sentido Formal: Toda norma emanada del Poder Legislativo según el procedimiento constitucional.

Sentido Material: Toda norma emanada por una autoridad competente (incluye decretos del poder ejecutivo, resoluciones, la Constitución, edictos policiales, etc.). La concepción formal es más amplia al incluir actos del Congreso que no son leyes en sentido material (declaraciones, beneficios a personas determinadas, etc.).

Clasificación de las leyes:

Según su contenido: Autónomas o completas (contienen toda la preposición lógica), No autónomas o incompletas (definiciones legales, explicativas, modificadoras o limitativas).

Por su estructura:
Rígidas: Disposición precisa y concreta, aplicación limitada a la comprobación de presupuestos de hecho y consecuencia única. Ejemplo: "La mayoría de edad se cumple a los 21 años."

Flexibles: Permiten al juez mayor libertad en la interpretación e integración de la norma. Contienen fórmulas elásticas que involucran la opinión social, convicciones religiosas y la formación del operador jurídico. Ejemplo: "buenas costumbres" (art. 953 Cód. Civil), "buen padre de familia", "deber de obrar con prudencia".

Por el nivel de validez en relación a la voluntad de las personas:
Imperativas:

Prevalecen sobre la voluntad de las partes; las convenciones en contrario son nulas.

Supletorias: Las partes pueden dejarlas de lado de común acuerdo. Su objeto es suplir omisiones contractuales. Si las partes no están de acuerdo con la solución legal, pueden apartarse de ella mediante una cláusula contraria. La importancia de esta clasificación radica en que regula la libertad contractual. Las normas supletorias han disminuido por la crisis en el concepto de igualdad negocial.

La Costumbre: Para que sea fuente de derecho, debe reunir dos elementos básicos:

Elemento Material: Repetición constante y uniforme de conductas en una sociedad.

Elemento Subjetivo: Percepción de dicha conducta como obligatoria. Esto la diferencia de los usos o costumbres sociales. La importancia de la costumbre ha variado; en ordenamientos primitivos fue principal, pero luego cedió ante la formulación escrita. A partir del siglo XX, se revaloriza por criterios realistas de interpretación jurídica. El Código Civil argentino, en su concepción original (art. 17), solo le daba fuerza en los

casos en que la ley la receptara expresamente. La reforma de 1968 (ley 17.711) le otorgó fuerza legal en casos de silencio de la ley, pero sigue prohibiéndola cuando se opone al texto expreso de la ley.

La Jurisprudencia: Se refiere a "los fallos de los tribunales judiciales que sirven de precedentes a futuros pronunciamientos". No es necesario que los precedentes se extiendan en el tiempo; un solo pronunciamiento puede sentar jurisprudencia (llamado Leading Case). Su importancia radica en varios puntos:

La interpretación de una norma judicial no es única; es el poder judicial quien, en última instancia, delimita el alcance de un texto. Se menciona a iusfilósofos realistas americanos que sostenían que "la ley es lo que el juez dice que es".

La interpretación varía con los cambios en la ciencia jurídica y la realidad social. La interpretación judicial deja de ser un ejercicio mecánico y se convierte en una forma de auténtica creación jurídica, operando sobre el mismo texto pero apartándose de soluciones anteriores.

La ley no puede prever todos los casos fácticos, generando "lagunas del derecho". El juez está obligado a fallar y, al hacerlo, integra la norma, creando una solución no contemplada legalmente. Su pronunciamiento sirve de guía a otros sujetos del ordenamiento.

5. Efectos de la Ley con Relación al Tiempo

Se analizan dos cuestiones fundamentales: cuándo una ley se vuelve obligatoria y la posibilidad de la aplicación retroactiva.

Fecha de Entrada en Vigencia: El art. 2 del Código Civil determina la obligatoriedad a partir de su publicación. El plazo lo fija el legislador; si no, el código establece un plazo supletorio de ocho días desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial. Este requisito de publicación es esencial para la obligatoriedad. Aunque la publicidad real puede ser limitada, se mantiene la ficción jurídica del conocimiento de la ley por seguridad jurídica.

Aplicación Retroactiva de la Ley: Se refiere a la modificación de efectos anteriores a la entrada en vigencia de una nueva norma. Originalmente, el art. 3 del Código Civil prohibía el efecto retroactivo si afectaba derechos adquiridos. Sin embargo, esta fórmula generó controversia por la dificultad de definir "derecho adquirido". La ley 17.711 modificó el art. 3 estableciendo: "A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplicarán aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. No tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley, en ningún caso puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales." "A los contrato en curso de ejecución, no son aplicables las nuevas leyes supletorias."

Se analizan dos hipótesis:

Situaciones jurídicas generales: Derechos regidos por la ley y no por la voluntad de las partes (ej. derechos reales, relaciones de familia). La ley se aplica desde su entrada en vigencia.

Relaciones regidas por la voluntad de las partes (contratos): Normas Imperativas: Su aplicación comienza desde su entrada en vigencia.

Normas Supletorias: La modificación no tiene efectos respecto a contratos ya iniciados. Esto se basa en que la norma supletoria integra el contrato en ausencia de disposición contraria, y aplicar una nueva norma supletoria implicaría modificar la voluntad contractual original.

La ley limita la retroactividad a los casos en que no se afecten derechos amparados por garantías constitucionales. Aunque se eliminó la referencia a los derechos adquiridos, ninguna ley puede afectar un derecho constitucional debido al principio de supremacía constitucional. Sin embargo, se aclara que los derechos constitucionales no son absolutos y son susceptibles de regulación si no se desnaturaliza su esencia. La Corte Suprema ha aceptado la constitucionalidad de las leyes de emergencia en repetidas ocasiones.

6. Elementos de las Relaciones Jurídicas

Toda relación jurídica implica la existencia de ciertos elementos:

Los Sujetos: Son las personas, ya sean de existencia física o legal (sociedades, fundaciones, etc.), que pueden ser titulares de derechos y obligaciones. Se clasifican en:

Las Partes: Aquellos que se han obligado a cumplir cierta conducta o son titulares de un derecho en una relación jurídica. Se diferencia de los firmantes u otorgantes (ej. mandatario). Los sucesores universales de una persona fallecida son considerados partes (continúan el lugar jurídico del causante), aunque existen excepciones (obligaciones intuitu personae, acuerdo de resolución por muerte, aceptación con beneficio de inventario).

Los Terceros: Todo aquel que no es parte de una relación jurídica. Como principio general, los actos de las partes no tienen efectos contra terceros, salvo en la transmisión de derechos reales que son oponibles a cualquier persona.

La Causa: Tiene dos acepciones:

El hecho del que derivan las obligaciones (hecho ilícito, voluntad de las partes, la ley).

El fin que las partes se propusieron al contratar (el sentido de interés en el texto).

Según la doctrina, es el fin inmediato y determinante que no puede ser ignorado por la contraparte. Se diferencia de los meros motivos, que son las motivaciones psicológicas sin efectos jurídicos inmediatos. La regulación principal está en los art. 500 y 502 del Código Civil. El art. 500 establece una presunción de existencia de la causa por seguridad jurídica. Si la causa no existe, es contraria a derecho o es falsa pero oculta una válida (acto simulado), la relación jurídica puede ser nula (art. 502), aunque en el caso de simulación con causa real válida, el acto simulado se mantiene, siendo de importancia para terceros que pueden oponer el acto si les conviene.

El Objeto: Refiere a la cosa o hecho sobre el cual recae la obligación, es decir, la prestación debida. Es un elemento fundamental. No todo objeto es válido; debe cumplir lo normado por el art. 953 del Código Civil: "El objeto de los actos jurídicos deben ser cosas que estén en el comercio o que por un motivo especial no se hubiese

prohibido que sean objeto de un acto jurídico o hechos que no sean imposibles, ilícitos contrarios a las buenas costumbres o prohibidos por las leyes o que se opongan a la libertad de las acciones o de la conciencia o que perjudiquen los derechos de un tercero. Los actos jurídicos que no sean conforme a esta disposición son nulos como si no tuviesen objeto."

El objeto debe cumplir tres condiciones básicas:

Debe ser Posible: Posibilidad física absoluta (no relativa al contratante).

Debe ser Lícito: No contrario al ordenamiento jurídico.

Debe ser Conforme a la Moral y las Buenas Costumbres: Este es un estándar jurídico que se evalúa en el caso concreto. La jurisprudencia califica ciertas actividades como contrarias a la moral (ej. locación para casas de citas, pactos de retroventa como garantía, intereses usurarios). Los efectos de la ilicitud del objeto dependen de si constituye una parte esencial o un accesorio de la convención.

Estructura Constitucional

El texto introduce la distinción entre dos conceptos de Constitución que, si bien relacionados, no son idénticos:

Constitución Formal: Se refiere al "texto legal sancionado por un órgano particular, la convención constituyente". Sus características principales son:

Es una ley escrita.

Está reunida en un texto único y sistematizado.

Es sancionada por la convención constituyente, no por el poder legislativo.

Constituye la norma fundamental del ordenamiento jurídico.

Tiene un "carácter supra legal, de forma tal que todo el contenido del ordenamiento jurídico se puede derivar del mismo".

Constitución Material: Representa "cómo funciona el esquema de poder de un estado", incluyendo su "real aplicación". Existe en todos los estados, incluso si no tienen un texto escrito, ya que están constituidos o funcionan de una manera determinada. La Constitución material "excede el contenido de la [formal]", incorporando elementos fuera del texto, como la jurisprudencia de los tribunales.

El texto señala que la Constitución formal y la material pueden coincidir, pero también pueden presentar discrepancias. Esto ocurre cuando cláusulas del texto formal caen en desuso (ej. potestad de otorgar patentes de corso) o nunca llegan a implementarse (ej. regulación del juicio por jurados).

El contenido de ambas constituciones abarca dos grandes áreas:

La "parte orgánica": Se refiere al "ejercicio del poder, en lo referente a la conformación de los órganos de gobierno, su funcionamiento y capacidades".

La "parte dogmática": Se refiere a la "posición de los sujetos frente al estado", es decir, los derechos y garantías de los ciudadanos.

2. Principio de Supremacía Constitucional

Este principio establece la jerarquía del orden jurídico. Se cita el Artículo 31 de la Constitución Nacional Argentina, que declara:

"Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella..."

Esta visión es consistente con la teoría de Hans Kelsen, quien conceptualizaba el ordenamiento jurídico como una estructura piramidal donde la Constitución es el "vértice superior y el fundamento lógico de las restantes normas". La supremacía constitucional implica una "graduación jerárquica del orden jurídico derivado" donde "los más altos subordinan a los inferiores y todo el conjunto debe ajustarse al contenido de la constitución".

Cuando una norma inferior contradice la Constitución, se produce la inconstitucionalidad. Tales actos carecen de validez y se reputan nulos para mantener la "estructura lógica" del ordenamiento.

Para detectar y declarar las normas inconstitucionales, existen los sistemas de control o revisión constitucional. Por principio, "todos los actos y normas, ya sea de particulares o del propio estado, se encuentran sujetos al control constitucional". Sin embargo, se menciona la excepción de las "cuestiones políticas no judiciales", aunque se aclara que esto no implica que la supremacía constitucional no exista en estos casos, sino que "la misma no puede ser ejercida mediante una acción ante el organismo de control". El control se limita a la concordancia con el texto constitucional, no a la "oportunidad de la medida".

Los mecanismos de control constitucional se clasifican según:

Órgano de control:

Político: El órgano está en la órbita del poder político (ej. Tribunal de Control Constitucional de Francia).

Jurisdiccional: El control reside en la administración de justicia.

Difuso: Todos los jueces pueden ejercer el control.

Concentrado: Existe un único organismo encargado de la declaración de inconstitucionalidad.

Vías procesales:

Directo: La demanda tiene como objeto principal la declaración de inconstitucionalidad.

Indirecto: La cuestión constitucional es incidental dentro de una pretensión principal diferente (ej. declaración de inconstitucionalidad de una ley en un juicio de desalojo).

Efectos de la declaración:

Limitados o inter-partes: Se limitan al caso bajo estudio.

Amplios o erga omnes: Se extienden a todos los casos comprendidos en la norma.

En el gobierno federal argentino, el control constitucional es exclusivamente judicial y es potestad de todos los jueces ("difuso"). Se ejerce por vía incidental y con efectos "limitados a las partes". Sin embargo, en algunas constituciones provinciales, existen acciones de declaración de inconstitucionalidad directas, a menudo reservadas al superior tribunal local ("concentrado"), con efectos que pueden ser entre partes o, en constituciones más modernas, con efectos generales (ej. Río Negro, Santiago del Estero, Neuquén).

3. Las Garantías Constitucionales

Las garantías constitucionales son "mecanismos de protección jurídica de los particulares frente a estado, a los efectos de que este asegure la vigencia de los derechos consagrados a los ciudadanos". En un sentido estricto, se refieren a "procesos judiciales comprendidos en el art. 43 de nuestra constitución nacional".

El Artículo 43 de la Constitución Nacional (citado en el texto) establece tres acciones principales:

Acción de Amparo: Procedente "siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley". También aplica contra la discriminación, y derechos ambientales, de competencia, usuario y consumidor. El juez "podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva".

Históricamente, el amparo fue una "creación jurisprudencial" no receptada constitucionalmente hasta 1994. Casos como "Siri" (1957) y "Kot" (1958) fueron fundamentales para su reconocimiento.

La ley 16.986 limitó su procedencia, exigiendo que el agravio derivara de un acto "manifiestamente ilegal o arbitrario" y que "exista otras vías o recursos administrativos o judiciales para impugnar el acto".

La reforma de 1994 (Art. 43) modificó esto, permitiendo el amparo "en el caso que no exista una vía judicial más idónea", eliminando la necesidad de agotar la vía administrativa y exigiendo que las vías alternativas sean igualmente idóneas.

Acción de Habeas Corpus: Tutela la "libertad física o ambulatoria de una persona contra acciones que de cualquier forma la restrinjan en forma arbitraria o sin formas legales". Procede a pedido del particular o de oficio. Es un procedimiento abreviado que garantiza audiencia y puede resultar en una orden judicial (auto de habeas corpus) para informar sobre la detención o presentar a la persona. El artículo 43

Menciona su procedencia en casos de "agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o en el de desaparición forzada de personas", incluso "aun durante la vigencia del estado de sitio".

Acción de Habeas Data: Tuvo su origen en la reforma constitucional de 1994. Es una "figura específica del amparo, destinada a proteger los datos personales". El artículo 43 establece que "Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos". Se prohíbe afectar el "secreto de las fuentes de información periodística".

Aunque estas son acciones de índole constitucional, su "regulación procesal queda supeditada a la reglamentación que las provincias decidan darle en sus códigos forma".

4. Forma del Estado y del Gobierno

El Artículo 1 de la Constitución Nacional Argentina (citado en el texto) establece:

"La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, según la establece la presente Constitución."

El texto diferencia entre Forma de Gobierno y Forma del Estado:

Forma de Gobierno: "el modo en que un gobierno ejerce el poder sobre la población sometida a su soberanía".

Forma del Estado: "las posibles maneras en que el poder se distribuye en el espacio físico de un territorio determinado".

Formas de Gobierno: Monarquía y República

Se menciona la clasificación de Aristóteles (monarquía, aristocracia, democracia y sus formas degradadas: tiranía, oligarquía, demagogia), pero se critica su "componente axiológico". Se prefiere la separación clásica sin contenido de valor esbozada por Nicolás Maquiavelo entre Monarquía y República.

Monarquía: El estado está "encarnado en la figura de una persona determinada (el príncipe, rey o cualquier otro término a utilizar)". Existen dos vertientes:

Monarquía Constitucional: El monarca representa al estado pero no ejerce el poder directo, que recae en gobiernos elegidos democráticamente (ej. España actual). El rey "manda pero no gobierna".

Monarquía Absoluta: La voluntad del soberano se confunde con la del estado, y el monarca "permaneciendo el monarca fuera del ordenamiento jurídico que el mismo crea" (ej. monarquías europeas del siglo XVIII, algunos países de oriente medio actuales).

República: El ejercicio del poder está "descorporizado, siendo ejercido por un conjunto de magistraturas en las que las personas que las ocupan resultan indiferentes". Se basa en la idea de un "mandato popular ejecutado por personas elegidas como representantes". Sus características jurídicas son:

División de Poderes: La función estatal se divide entre poderes (ejecutivo, legislativo, judicial) que cumplen actividades específicas y se limitan mutuamente.

Principio de igualdad: Entendida como la "inexistencia de diferencias irrazonables entre personas que se encuentran en la misma situación de hecho". Las diferencias de trato deben sustentarse en principios razonables.

Elección popular de los gobernantes: El poder de los gobernantes radica en el mandato de la población. Se cita el caso Alem de 1893: "En nuestro mecanismo institucional, todos los funcionarios públicos son meros mandatarios que ejercen poderes delegados por el pueblo, en quien reside la soberanía originaria".

Temporalidad de los cargos de gobierno: Necesidad de renovación periódica de los cargos (salvo los jueces para salvaguardar su autonomía).

Responsabilidad de los gobernantes: Los gobernantes no están excluidos del ordenamiento jurídico y sus actos tienen consecuencias similares a las de un particular.

Publicidad de los actos de gobierno: Las leyes y reglamentos deben ser conocidos por la población (ej. publicación en el Boletín Oficial).

Formas del Estado: Sistemas Unitarios y Federales

Definen la "manera en que el poder del estado se encuentra distribuido en un territorio determinado".

Estado Unitario: Existe un "poder único y central que delega funciones en las administraciones locales una serie de funciones que le competen originariamente".

Estado Federal: Se configura por la unión de estados locales ya existentes, que "delegan en el poder central una serie menor o mayor de facultades" (ej. cantones suizos, colonias estadounidenses). La consecuencia principal es que las competencias otorgadas al estado nacional tienen un "carácter restrictivo". Si las provincias son preexistentes a la nación, "toda facultad no delegada le sigue perteneciendo".

El texto señala que la existencia de un estado federal no implica necesariamente mayor independencia local; la autonomía política depende de la "real distribución de potestades". Se compara la mayor limitación de las provincias argentinas en comparación con las comunidades autónomas de España, a pesar de que Argentina es un estado federal.

El caso argentino es "particular" debido a su esquema histórico: de un Virreinato centralizado a la persistencia de las provincias, que luego se reúnen y dan forma al estado nacional federal en 1853. Esta adopción fue un "compromiso entre ambas posiciones" (unitarismo vs federalismo) con "amplias atribuciones para el estado central". Esto lleva a una "tendencia a la centralización de las funciones". Por ejemplo, las competencias legislativas de fondo corresponden al estado federal, mientras que

las provincias se encargan de la "legislación de forma", es decir, cómo se ejercen los derechos en sede judicial.

Hechos y Actos Jurídicos

1. Introducción

Este documento de información presenta una revisión de los conceptos fundamentales de hechos y actos jurídicos, así como la clasificación y características de los instrumentos públicos y privados, basándose en los principios del Código Civil Argentino. Se destacan las definiciones clave, las distinciones importantes y las implicaciones legales de estos conceptos.

2. Hechos Jurídicos

Concepto: Un hecho jurídico es un acontecimiento del mundo real que conlleva una consecuencia jurídica. "Para que podamos hablar de hechos jurídicos debemos necesariamente referirnos a aquellos eventos del mundo real que conllevan una consecuencia jurídica." No todos los hechos físicos son hechos jurídicos; un hecho físico se convierte en jurídico cuando la ley le atribuye efectos legales.

Clasificación: La clasificación más relevante distingue entre hechos humanos y de la naturaleza, según si interviene la voluntad humana o no.

3. Hechos Voluntarios e Involuntarios

Hechos Voluntarios: Según el art. 897 del Código Civil, los hechos voluntarios son aquellos realizados con discernimiento, intención y libertad. El art. 900 establece que la falta de alguno de estos elementos no genera obligación alguna, aunque la fuente señala que "dicho principio se encuentra muchas veces contradicho por el propio código."

Elementos de los Hechos Voluntarios: Discernimiento: La capacidad de analizar y comprender las acciones. El Código no lo define, pero el art. 921 enumera los actos que se reputan hechos sin discernimiento (menores, dementes, personas sin uso de razón). La fuente critica este sistema, señalando que la realidad a menudo se aparta de esta regla general.

Intención: La pretensión de lograr los resultados naturales derivados del acto. Implica la representación y aceptación de un resultado. Puede estar viciada por:

Error: Desconocimiento de las circunstancias de hecho que rodean el acto.

Dolo: Inducción al error para que el sujeto realice una actividad determinada.

"Aplicada a los vicios en los actos jurídicos, la palabra dolo es utilizada a los efectos de referir a la actividad tendiente a engañar a un sujeto de derecho a los efectos que realice una actividad determinada." La fuente destaca que si el dolo es recíproco, el acto es válido, lo que representa una excepción al principio general.

Libertad: Capacidad del sujeto para optar por realizar o no el hecho. Puede estar viciada por:

Violencia: Amenaza cierta o inminente que impide al autor tomar una decisión independiente. Puede ser física o mediante amenaza.

Hechos Involuntarios: Aquellos realizados sin discernimiento, intención o libertad.

4. Actos Lícitos e Ilícitos

Clasificación: Dentro de los hechos humanos voluntarios, se distinguen los actos lícitos (conformes a la ley) y los ilícitos (contrarios al ordenamiento jurídico).

Hecho Ilícito Civil: Requiere la concurrencia de tres elementos:

Ser contrario a la ley.

Ser culpable (dolo o culpa).

Haber ocasionado un daño a terceros. El daño no necesariamente debe ser efectivo, pudiendo ser potencial ("la mera pérdida de chances constituye un daño posible de configurar un acto ilícito civil").

Culpabilidad:Culpa: El daño se produce sin intención directa, por omisión de reglas del arte o negligencia. "Así, el código civil reputa voluntarios a estos actos a pesar de la falta de intención de dañar."

Dolo: Presupone una intención de dañar (dolo simple) o al menos una falta de preocupación por el resultado (dolo eventual). La diferencia con la culpa radica en la representación del resultado.

Distinción entre Delitos y Cuasidelitos (en el sistema del Código):Delitos: Hechos ilícitos realizados con dolo.

Cuasidelitos: Hechos ilícitos realizados con culpa.

Implicancias Prácticas: Diferencias en la responsabilidad por consecuencias casuales, la acción de repetición entre coautores y la potestad judicial de reducir la indemnización según el estado patrimonial en los cuasidelitos.

5. Actos Jurídicos

Concepto: El art. 944 del Código Civil Argentino define a los actos jurídicos como "los voluntarios lícitos, que tengan por fin inmediato establecer entre las personas relaciones jurídicas, crear, modificar, transferir, conservar o aniquilar derechos."

Elementos:Son actos voluntarios.

Son lícitos.

Tienen por fin inmediato la producción de efectos jurídicos. Esta última característica es la que los diferencia de otros actos lícitos.

Clasificación:Entre vivos y de última voluntad: Dependen o no del fallecimiento de quien los otorga (ejemplo de última voluntad: testamento).

Formales y No Formales: Su existencia o eficacia dependen del cumplimiento de formas definidas (formales) o no (no formales).

De administración y de disposición o enajenación: Tienden a mantener/aumentar el patrimonio (administración) o implican un cambio significativo en la composición patrimonial (disposición). Es un criterio económico, un mismo acto puede ser diferente según la persona.

Principales y accesorios: Existen por sí mismos (principales) o dependen de otro acto al que complementan (accesorios, ejemplo: fianza de un contrato de alquiler).

Elementos y Estructura: Sujeto, objeto y causa, al igual que en la relación jurídica.

6. Forma de los Actos Jurídicos

Concepto: La obligación de respetar ciertas actividades normadas por el ordenamiento jurídico para la validez o eficacia de un acto.

Evolución Histórica: Desde un formalismo extremo en el derecho romano (solemnidades como requisito ineludible) hasta un enfoque en la voluntad en el código francés, y un retorno parcial al formalismo en el derecho moderno debido a la complejidad y el crecimiento de los centros urbanos (necesidad de registros públicos).

"Este formalismo no constituye requisito de existencia como en lo fue en el derecho romano, sino que se otorga en beneficio de las partes, y en particular, de los terceros."

Formalidades Solemnes y No Solemnes: Solemnes: La inobservancia de las formas conlleva la nulidad del acto.

No Solemnes: La inobservancia solo afecta la prueba del acto y su oponibilidad a terceros. Si la ley no especifica, se entiende que el acto no es solemne para favorecer la validez del acto.

7. Instrumentos Privados

Concepto: Instrumentos otorgados por las partes sin intervención de un oficial público.

"Respecto a ellos, el principio que impera es la libertad de las formas respecto a su confección y su otorgamiento."

Requisitos Formales: La firma: Elemento esencial. La manera habitual de escribir el nombre y apellido para asumir responsabilidades. La habitualidad es clave. Las siglas y otros signos no son válidos en principio (art. 1012), aunque la jurisprudencia ha flexibilizado esto para personas que pueden darse a entender por escrito. La impresión digital es contradictoria en jurisprudencia, dependiendo si el firmante sabe leer y escribir.

El doble ejemplar: Fundamentado en el art. 1021 del Código Civil para actos con convenciones bilaterales perfectas. Busca poner a las partes en igualdad de condiciones para la prueba. Es de orden público y no puede renunciarse. Se requieren tantas copias como partes con interés distinto. Basta con que cada ejemplar esté suscrito por la contraparte. Existen excepciones donde no se requiere el doble ejemplar (cumplimiento total de una parte, cumplimientos parciales de ambas, depósito en un tercero). La falta del doble ejemplar causa la nulidad del instrumento, no del acto en sí, el cual puede probarse por otros medios.

Fuerza Probatoria: Requieren reconocimiento de quien lo suscribió para tener capacidad probatoria. Si se desconoce la firma, se ordena un cotejo pericial. La excepción es la firma certificada por escribano público, donde se requiere un procedimiento de querrela de falsedad para demostrar falsificación.

Respecto a las partes: Hace fe pública sobre el contenido material (se requiere querrela de falsedad para probar falsificación o adulteración). Respecto a las

manifestaciones vertidas, solo hace fe hasta prueba en contrario (basta un contradocumento, testigos, etc.).

Respecto a terceros: Tienen la misma fuerza probatoria que con respecto a las partes solamente después de obtener fecha cierta. Los casos de fecha cierta se enumeran en el art. 1035 (presentación en juicio/autoridad administrativa, reconocimiento ante escribano/testigos, transcripción en registro, fallecimiento de una parte).

8. Instrumentos Públicos

Concepto: Otorgados con intervención de un oficial público y las formalidades de ley (definición clásica). Sin embargo, el art. 979 del Código Civil incluye casos sin oficial público. Lo que les confiere su calidad es su autenticidad, que prueban por sí mismos sin necesidad de reconocimiento posterior.

Requisitos: Intervención de un Oficial Público: Regla general. Debe cumplir con competencia funcional (legalmente nombrado, dentro de sus funciones) y territorial (en su jurisdicción). Actos de oficiales no calificados son válidos para no perjudicar a las partes.

Cumplimiento de las formalidades legales: Varían según el instrumento. Común a todos es la firma de todos los participantes (art. 988), bajo pena de nulidad. Si alguien no sabe/puede firmar, el oficial deja constancia y otra persona firma por él.

Enumeración Legal (art. 979 Código Civil, lista cerrada): Escrituras públicas realizadas por escribanos en sus libros de protocolos (la más común e importante).

Actas judiciales hechas por secretarios de juzgado.

Asientos de libros de corredores (poco aplicable).

Asientos parroquiales (histórico, reemplazado por el Registro Civil).

Cualquier otro instrumento extendido por escribanos o funcionarios públicos según lo determine la ley (categoría amplia que incluye informes de registros, partidas de registro civil, actas legislativas, etc.).

Valor Probatorio: Gozan de autenticidad. Prueban su contenido por sí mismos. Se distingue la fe según la cláusula:

Hechos cumplidos por ante el oficial público: Hacen plena fe hasta su impugnación. Se refiere solo a lo que el oficial vio u oyó (no a apreciaciones personales).

Manifestaciones de las partes: Respecto a actos anteriores, pagos, etc., hacen fe hasta prueba en contrario. No requiere impugnación formal, basta otra prueba. El hecho de haber realizado las manifestaciones por ante el oficial sí mantiene fe pública.

Simples enunciaciones: Detalles que acompañan el negocio. Si están directamente vinculadas con el objeto del contrato, hacen plena fe respecto a las partes y terceros. Si no están directamente vinculadas, hacen plena fe respecto a las partes pero son inoponibles a terceros.

Impugnación del Instrumento Público: La parte que intenta impugnar tiene la opción de:

Vía civil por redargución de falsedad: Dirigida contra todos los intervinientes. Puede ser acción independiente o incidente en juicio. No procede en juicios ejecutivos.

Acción penal por falsificación de instrumento público: Busca la condena del oficial público y, secundariamente, cosa juzgada sobre la falsedad.

Este documento proporciona un resumen conciso de los conceptos clave y las distinciones importantes presentadas en la fuente, utilizando citas directas cuando es apropiado para ilustrar los puntos principales.

Contratos

1. Concepto de Contrato:

El documento comienza definiendo el contrato según el Art. 1137 del Código Civil argentino: "Habra contrato cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común destinada a reglar sus derechos."

De esta definición se desprenden cuatro características fundamentales:

Necesidad de concurrencia de dos o más personas: A diferencia de otros ordenamientos, el derecho argentino no reconoce el "auto contrato".

Manifestación de voluntad individual: Cada persona involucrada debe realizar un acto jurídico manifestando su voluntad.

Manifestaciones concurrentes: Las voluntades deben dirigirse hacia la celebración de un contrato específico (oferta o aceptación).

Generación o modificación de derechos y obligaciones: El acuerdo debe tener como fin crear o modificar un vínculo jurídico. Algunos autores, como Guillermo Borda, critican que la redacción no incluya la extinción de derechos y obligaciones, lo que se denomina "distracto".

2. Evolución Histórica del Contrato:

La evolución histórica del contrato refleja la relación entre las formas contractuales, las estructuras de poder y la circulación de bienes.

Concepción Romana: La voluntad de las partes no era esencial. La fuerza obligatoria provenía de la forma y el reconocimiento estatal (del "príncipe"). Los acuerdos debían adecuarse a tipos preestablecidos y cumplir formalidades. Recién con Justiniano se permitió una acción judicial para forzar el cumplimiento de acuerdos no previstos, pero basada en la equidad y la realización previa de una prestación.

Concepción Francesa (Post Revolución Francesa): La voluntad se convierte en la base de la obligación contractual. Fundamentada en la idea de la libertad e igualdad natural de los hombres, se postula que deben tener derecho a determinar sus relaciones sin intervención estatal, salvo para el cumplimiento forzoso en caso de incumplimiento. La función del derecho se limita a otorgar fuerza obligatoria a lo acordado libremente.

Crítica a la Concepción Francesa y la Realidad Moderna: Esta concepción confunde la igualdad jurídica con la igualdad económica. Es insostenible en economías de masas, donde operadores con mayor capacidad económica pueden imponer sus condiciones. Además, en los grandes conglomerados urbanos, el conocimiento personal entre contratantes es imposible, generando inseguridad jurídica para terceros de buena fe que adquieren bienes vendidos previamente.

Concepción Moderna (Intervención Estatal): Existe un retorno a la intervención estatal, pero con una finalidad diferente: proteger a terceros y a la parte más débil de la relación contractual. El estado adopta un papel tutelar, limitando la autonomía de la voluntad cuando puede derivar en resultados "disvaliosos".

3. Aplicación del Principio Moderno de Intervención Estatal:

La intervención estatal se manifiesta principalmente a través de tres fenómenos:

Dirigismo Contractual: El estado limita la capacidad de disposición de los contratantes en casos donde está involucrado el interés público. Ejemplos incluyen la legislación detallada en el contrato de trabajo para proteger al trabajador (parte más débil), estableciendo "un piso de derechos". Cualquier convención que supere este mínimo es válida.

Nuevas Formas Contractuales: La estructura clásica (libre acuerdo entre particulares) se ve modificada.

Contratos de Adhesión: Una de las partes predispone las cláusulas y la otra se limita a aceptar o rechazar. Común en economías de masas, requiere una interpretación particular dada la incapacidad de modificación por una parte.

Convenios Colectivos: Tienen carácter público y alcanzan a más personas que los celebrantes (organización sindical y empresariado). Negociación general aplicable a todas las relaciones laborales de la especialidad. Su carácter contractual es discutido por algunos autores debido a la injerencia del derecho público y la necesidad de homologación estatal en Argentina, que otorga la fuerza obligatoria.

Contratos Forzosos: La forma más extrema de limitación, eliminando casi totalmente el consentimiento. Ejemplos históricos son las leyes de agio que obligaban a vender mercaderías a precio prefijado, limitando solo la elección del cocontratante. Se basan en el interés público para limitar libertades económicas provisionalmente en pos del "bien común".

Posibilidad de Revisión Judicial de lo Acordado: Permite a los jueces intervenir para corregir desequilibrios o abusos (mencionado brevemente en relación a la buena fe y circunstancias sobrevinientes, aunque sin desarrollar plenamente en este punto).

4. Clasificación de los Contratos:

Las clasificaciones son modelos arbitrarios pero útiles para organizar el análisis. Un contrato puede presentar características de varias categorías.

Contratos Bilaterales: Generan obligaciones para ambas partes simultáneamente (ambos son acreedor y deudor, ej. compraventa). Relevante para la excepción de incumplimiento y el pacto comisorio.

Contratos Unilaterales: Las obligaciones surgen en un solo sentido (ej. donación).

Contratos Gratuitos: No hay contraprestaciones económicamente apreciables. Se distingue de bilateral; un contrato puede ser bilateral pero no oneroso (ej. contratos de servicios vía web con obligaciones de abstención).

Contratos Onerosos: Las contraprestaciones son económicamente apreciables, no necesariamente en dinero (ej. permuta).

Contratos Principales: Se bastan a sí mismos, no dependen de otra convención.

Contratos Accesorios: Tienen un sentido instrumental y están subordinados a un contrato principal (ej. fianza como garantía de un alquiler).

Contratos Nominados: Se encuentran legislados en el ordenamiento jurídico. La regulación puede ser imperativa (no permite apartarse) o supletoria (regulación por defecto que suple el silencio de las partes).

Contratos Innominados: No tienen una regulación legal específica.

5. Formación del Contrato:

La formación del contrato requiere la concurrencia de al menos dos voluntades: oferta y aceptación.

Oferta: Proposición unilateral de una parte a otra para celebrar un contrato.

Según el Art. 1148 del Código Civil argentino, la oferta debe contener todos los elementos del negocio jurídico y estar dirigida a sujetos determinados. Las propuestas a personas indeterminadas son invitaciones a ofertar.

Excepción: En contratos de consumo, la publicidad de ofertas a personas indeterminadas constituye una oferta obligatoria (ej. publicidad de supermercado).

Duración: La oferta es revocable antes de la aceptación, salvo que se haya limitado expresamente esta posibilidad. Si la otra parte acepta desconociendo la retractación y realiza gastos, tiene derecho a resarcimiento pero no a exigir el cumplimiento.

Aceptación: Acto que consume el acuerdo de voluntades.

Debe ser lisa y llana, es decir, sin modificar los términos de la oferta. Si hay modificaciones, constituye una nueva oferta que requiere aceptación del oferente original.

Debe realizarse en tiempo oportuno, antes de la retractación del oferente.

Contratos entre Ausentes: Se discute el momento en que la aceptación perfecciona el contrato (declaración, envío, recepción, conocimiento).

Regla General en Código Civil Argentino: El Art. 1154 establece que el contrato se perfecciona al momento del envío de la aceptación.

Excepción: El aceptante tiene derecho a retractarse hasta que el oferente haya tomado conocimiento de la aceptación (Art. 1155).

6. Elementos de los Contratos:

Los Sujetos: Necesaria existencia de sujetos de derecho (físicos o legales).

Partes: Aquellos que se obligan o son titulares de un derecho por sí o por representante. Se diferencia de "firmantes" u "otorgantes". Los sucesores universales se consideran partes (continúan el lugar jurídico del causante), salvo excepciones:

Obligaciones "intuitu personae" (basadas en cualidades personales del fallecido).

Acuerdo de las partes para resolver el contrato por fallecimiento.

Aceptación de la sucesión con "beneficio de inventario" (los patrimonios no se mezclan, limitando la responsabilidad del heredero).

Terceros: Aquellos que no son parte de la relación jurídica. Como principio general, los actos de las partes no les afectan, salvo la transmisión de derechos reales que son oponibles a todos.

La Causa: Tiene dos acepciones: el hecho que genera las obligaciones (ej. ilícito, voluntad, ley) y el fin que las partes se propusieron al contratar.

En el contexto de los contratos, la causa es el fin inmediato y determinante que las partes tuvieron, conocido por la contraparte.

Se diferencia de los meros motivos (motivaciones psicológicas) que no tienen efectos jurídicos inmediatos.

Regulación (Arts. 500 y 502 C.C.): Se presume la existencia de la causa (Art. 500), incluso si no está expresada. La prueba de su inexistencia o falsedad recae sobre quien la alega.

Problemas de Causa: Causa Inexistente o Contraria a Derecho: Anula la relación jurídica (Art. 502).

Causa Falsa: Si la causa manifestada es falsa pero oculta otra válida, el acto simulado se mantiene (ej. simulación en perjuicio de acreedores). Esto es relevante para terceros.

El Objeto: La cosa o hechos sobre los que recae la obligación (la prestación debida). Es un elemento fundamental.

Debe cumplir las condiciones del Art. 953 del Código Civil:

Posible: La posibilidad física debe ser absoluta, no relativa al contratante.

Lícito: No debe ser contrario al ordenamiento jurídico.

Conforme a la moral y las buenas costumbres: Un estándar jurídico que evoluciona.

Incluye no solo cuestiones sexuales sino también cláusulas económicas abusivas (ej. usura).

Efectos de un Objeto Ilegítimo: Si el objeto es esencial, anula toda la convención. Si es accesorio (ej. cláusulas de retroventa o intereses usurarios), puede afectar solo esa cláusula, manteniendo la relación jurídica principal.

7. Efectos de los Contratos:

Principios Generales: El principal efecto es que las partes quedan obligadas a cumplir las cláusulas. El Art. 1197 del Código Civil establece que "las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma."

La condición de "parte" se diferencia de "signatario". La parte puede actuar por sí o por representante.

Principio de inoponibilidad a terceros: Los contratos no obligan a terceros (principio general con excepciones).

Excepción de los sucesores universales (considerados parte), aunque con limitaciones por el beneficio de inventario y acuerdos de disolución por muerte.

Excepción de cláusulas a favor de terceros (ej. beneficiario en seguro de vida).

Involucra múltiples relaciones jurídicas.

Límites a la Obligatoriedad: La autonomía de la voluntad tiene límites basados en la función social del contrato. Carecen de fuerza obligatoria:

Contratos contrarios a leyes de orden público (incluye cláusulas imperativas de contratos nominados).

Contratos contrarios a la moral (Art. 953), incluyendo cláusulas abusivas o usurarias.

Contratos que violan el principio de buena fe (Art. 1198), que exige ejecutarse y celebrarse de acuerdo a esta regla. Impide lucrar con la inexperiencia o necesidad ajena. También permite apartarse de lo acordado ante circunstancias sobrevinientes que modifiquen sustancialmente la ecuación económica.

La Excepción de Incumplimiento: Potestad de una parte de negarse a cumplir si la otra está en mora (no ha cumplido sus obligaciones).

Origen en el derecho romano.

Basada en la reciprocidad de las obligaciones en contratos bilaterales. Quien exige el cumplimiento no puede estar en mora.

Requisitos:

Contrato bilateral.

Obligaciones exigibles (no sujetas a plazo o condición no cumplidos).

Incumplimiento (total o parcial) de la otra parte. Debe haber un equilibrio entre el incumplimiento y la obligación a excepcionar para evitar abusos.

El Pacto Comisorio: Acuerdo entre partes para resolver el contrato en caso de incumplimiento, facultando a solicitar daños y perjuicios.

Tradicionalmente requería manifestación expresa.

Art. 1204 (modificado por decreto ley 17711/68) prevé dos situaciones:

Pacto Comisorio Tácito: Incluido por defecto si no se omite. Ante el incumplimiento, la parte cumplidora debe intimar a cumplir en un plazo no inferior a quince días (salvo pacto en contrario), más daños y perjuicios. Vencido el plazo, se puede resolver sin más.

Pacto Comisorio Expreso: No requiere intimación previa. Produce efectos desde la manifestación fehaciente de la parte comunicada.

Forma de Comunicación: Debe ser fehaciente (ej. carta documento) para establecer fecha cierta.

Efectos: El contrato queda sin efectos retroactivamente. Las partes deben restituirse lo recibido. La parte cumplidora tiene derecho a resarcimiento por daños.

Culpa Recíproca: Si ambas partes incumplieron, el juez puede declarar resuelto pero sin otorgar daños. Si la culpa no es equivalente, puede establecer una indemnización reducida.

Impedimento: La declaración de resolución impide exigir el cumplimiento del contrato.

Este informe sintetiza los puntos clave sobre el concepto, evolución, clasificación, formación y efectos de los contratos según los extractos proporcionados, destacando los conceptos fundamentales, las críticas históricas y las regulaciones específicas mencionadas (particularmente del Código Civil argentino).

Contratos Informáticos

1. Introducción y Concepto del Contrato Informático

Los contratos informáticos surgen como respuesta a la evolución tecnológica y el tratamiento de la información, dando lugar a figuras contractuales con características propias y principios jurídicos específicos. Se definen, en la doctrina argentina, como "todos aquellos negocios jurídicos que tienen por objeto los sistemas destinados a la gestión organizada de información." (Según Mosset Iturraspe).

Cita clave: Mosset Iturraspe define el instituto como "... la operación jurídica mediante la cual se crean, modifican, transmiten o extinguen relaciones obligacionales sobre bienes y/o servicios informáticos. Estos bienes se integran generalmente en un sistema, que el conjunto de elementos materiales o inmateriales, ordenados e independientes, vinculados con un objetivo común."

2. Características Singulares de la Contratación Informática (Según Bergel)

La contratación informática presenta particularidades que la distinguen de otros tipos de contratos:

- a) Acentuación de la distancia entre el proveedor y el cliente: Existencia de una brecha tecnológica y de conocimiento.
- b) Diferencias en los objetivos de las partes al contratar: Mientras el usuario busca un resultado funcional, el proveedor se enfoca en la entrega de bienes y servicios con especificaciones técnicas.
- c) Dificultades en la individualización del objeto contractual: El objeto es un sistema complejo, no un bien único y fácilmente definible.
- d) Parámetros relativos al incumplimiento de la prestación: El incumplimiento se relaciona a menudo con la falta de adecuación del sistema a los objetivos del usuario.
- e) Problemas suscitados con la redacción: La redacción contractual requiere precisión técnica y jurídica.
- f) Predominio de contratos mixtos y con cláusulas predispuestas: Combinación de elementos de diversos contratos y frecuente uso de condiciones generales.

3. El Problema de la Definición del Objeto: El Concepto de Sistema

La particularidad fundamental de los contratos informáticos es que su objeto es un "sistema": un conjunto de elementos materiales e inmateriales interrelacionados y ordenados con un objetivo común. A diferencia de productos más tradicionales, un sistema informático no tiene una funcionalidad ontológica; su utilidad y configuración dependen de los elementos que lo componen y su interconexión.

Cita clave: "Sistema será, entonces, el conjunto de bienes que permitan realizar la tarea específica solicitada por el usuario, de forma tal que la mera entrega de los componentes no satisface la obligación del proveedor sino que se hace necesaria su puesta en funcionamiento y la satisfacción de la necesidad del usuario."

Esta característica del sistema subraya la diferencia en la causa final de los contratantes. El usuario busca un resultado funcional específico, mientras que el proveedor busca la comercialización de un conjunto de bienes.

4. Desequilibrio Negocial y la Obligación de Información y Consejo

Existe un notorio desequilibrio en el conocimiento que las partes poseen sobre el objeto del contrato. El usuario generalmente carece del conocimiento técnico necesario y debe confiar en la información proporcionada por el proveedor, quien ejerce un monopolio de facto sobre esta información.

Cita clave: "... el usuario no posee el conocimiento técnico necesario para una toma de decisión fundada, sino que debe confiar en la información suministrada por el proveedor, quien ejerce, de facto, un monopolio sobre la información material y técnica que dará lugar al negocio jurídico."

Frente a esta realidad, surge la necesidad jurídica de eliminar la brecha tecnológica y reestablecer la igualdad negocial. Esto se materializa en la obligación del proveedor de informar y asesorar al usuario.

5. La Obligación de Información y el Deber de Asesoramiento y Consejo

Estas obligaciones derivan del principio de la buena fe contractual (aplicado, por ejemplo, en el artículo 1198 del Código Civil). Implican un deber de colaboración mutua para definir los componentes y extremos del sistema, asegurando que se adecuen a los objetivos pretendidos por el usuario.

Contenido del Deber de Consejo: Se circunscribe a lo relevante y suficiente para la toma de decisión del usuario. Tiene una doble faz:

Activa: El proveedor debe determinar las características técnicas esenciales, explicar los riesgos y la tecnología a incorporar.

Pasiva (Abstención): El proveedor no debe ser reticente u ocultar información pertinente.

Características de la Información (Según la Ley de Defensa del Consumidor, Art. 4°):

Veraz: Contenido sincero, no engañoso, que no omite datos esenciales.

Detallada: Permite al consumidor conocer las auténticas características del producto/servicio, relacionadas con sus necesidades. No es solo la enunciación técnica, sino cómo posibilita la concreción de objetivos.

Eficaz: Capacidad de generar una decisión informada en el usuario.

Suficiente: Detalles, descripciones y especificaciones aptas para una decisión reflexiva y con conocimiento de causa. La falta de suficiencia puede constituir dolo.

Naturaleza Jurídica del Deber de Consejo: El autor del texto se inclina a considerarla una obligación de resultado en la etapa de elaboración del consejo, dado el desequilibrio de conocimientos. Sin embargo, el deber se agota en la emisión del consejo; no garantiza el éxito final de la informatización, que depende de la calidad del material y su implementación. La responsabilidad por un resultado deficiente se derivaría de la información deficiente, no de una mala decisión del usuario informada.

6. El Deber de Colaboración del Usuario y la Elaboración del Cuadro de Necesidades

El principio de buena fe también impone deberes de diligencia al usuario, particularmente en la etapa precontractual. El usuario tiene la carga de:

Definir los elementos a informatizar.

Identificar las situaciones de hecho y características organizacionales sobre las que operará el sistema.

Proveer información sobre su organización, carga y condiciones de la tarea a informatizarse.

Cita clave: "Es el usuario quien debe definir cuales son los elementos a informatizar así como las situaciones de hecho y características organizacionales sobre los cuales dicha informatización producirá."

Históricamente, la jurisprudencia francesa cargaba la responsabilidad de definir las necesidades exclusivamente al cliente. Sin embargo, ha evolucionado para reconocer que el proveedor debe ayudar a la formulación de estas necesidades, corrigiendo posibles errores basándose en su conocimiento. Es un proceso de colaboración.

Usuarios Calificados y Asesores Externos: Si el usuario cuenta con conocimientos técnicos suficientes (departamento de informática) o contrata un consultor especializado, la diferencia entre lego y profesional se disipa, reestableciendo la igualdad negocial. En estos casos, la obligación de consejo del proveedor se limita o desaparece, trasladándose la responsabilidad al consultor si hay defectos en la definición de necesidades.

Naturaleza Jurídica del Deber de Informar del Usuario: Se considera una carga, no una obligación. Su incumplimiento no genera un daño al proveedor que este pueda exigir coercitivamente; el perjuicio recae sobre el propio usuario al obtener un sistema inadecuado.

Cita clave: "El concepto de carga, que nace del derecho procesal, es definido por el maestro Couture como "un imperativo en el propio interés"."

7. Aplicación en la Jurisprudencia Argentina

Aunque no existe una legislación específica de contratos informáticos en Argentina, la jurisprudencia ha receptado los conceptos clave:

"Sisteco S.A. c/ Sujoy Sergio" (CNCom, Sala E, 1986): Recepta el concepto de sistema, entendiendo que la aceptación y obligación de pago requieren la operación conforme del conjunto de elementos y su adecuación a los fines previstos. La "entrega" implica no solo la transmisión física sino que el sistema cumpla con los objetivos.

"Sistex S.A. c/Oliva S.A." (Suprema Corte de Mendoza, 1990): Establece los fundamentos del deber de consejo. Reconoce el desequilibrio técnico ("brecha tecnológica") y la disparidad de objetivos entre proveedor y usuario. De esta situación de hecho se extrae la obligación de información y consejo del proveedor.

Cita clave (Dra. Kemelmajer de Carlucci en "Sistex"): "Aunque el adquiriente o el usuario sea una persona avezada en el ramo comercial de su actividad, generalmente carece de suficientes conocimientos y experiencia en materia de utilización de equipos de elaboración electrónica de datos. En otros términos hay entre los contratantes una brecha tecnológica que se advierte en la tecnología empleada, poco comprensible para el hombre medio."

Cita clave (Dra. Kemelmajer de Carlucci en "Sistex"): "El usuario y el suministrados del servicio se aproximan a la negociación con actitudes radicalmente diferentes: El primero espera del contrato un cierto resultado funcional, el segundo en cambio, tiende a prometer una simple correspondencia del sistema de determinadas características y especificaciones técnicas."

8. Límites de la Obligación de Consejo

La obligación de consejo tiene límites temporales y materiales:

Temporales: Se extiende durante toda la vida contractual, fundamentada en la buena fe. Su contenido varía:

Etapas Precontractual: Elección de componentes y materiales.

Etapas Contractual: Formación de personal, reorganización del servicio, gestión de componentes.

Materiales: Ceñidos a lo estrictamente técnico. No abarca elementos fuera del área técnica del proveedor, como cálculos de rentabilidad (ámbito empresarial del usuario).

Ampliar estos límites violentaría la función del proveedor, el principio de buena fe (trasladando riesgos del usuario) y haría la contratación antieconómica.

Cita clave: "... esta parte entiende que el deber de consejo tiene sus límites materiales ceñidos a lo estrictamente técnico, sin que pueda reclamársele por errores que excedan dicho marco."

9. Garantías Específicas de los Contratos Informáticos

Existen garantías propias de esta categoría:

Compatibilidad: El sistema debe adaptarse a otros sistemas ya instalados por el usuario.

Escalabilidad: Posibilidad de migrar el sistema a arquitecturas superiores o distintas. Crucial por la velocidad del cambio tecnológico.

Modularidad: El sistema puede funcionar en módulos independientes.

Garantía de Propiedad Intelectual (Soporte Lógico): El proveedor debe asumir la defensa ante reclamos por derechos de propiedad intelectual del software.

10. El Concepto Moderno de Entrega: El Test de Aceptación

La "entrega" en contratos informáticos va más allá de la mera entrega física. Implica el cumplimiento integral de la prestación: instalación, puesta en funcionamiento, test de aceptación y aprobación.

El proveedor debe entregar manuales y documentación anexa. Salvo pacto en contrario o existencia de personal técnico en el usuario, la puesta en marcha es carga del proveedor. Las prestaciones deben cumplir con "buenos usos de la práctica informática" (normas técnicas, tecnología, concepción, etc.).

El test de aceptación es crucial para verificar que el equipo supera exigencias preestablecidas relacionadas con el objeto del contrato. La obligación de pago del precio a menudo se supedita a la superación de este test. Es fundamental que el test se elabore cuidadosamente, definiendo parámetros, métodos de comunicación de incumplimientos y soluciones. Los plazos para objeciones deben permitir un análisis completo del sistema por parte del usuario. Es común incluir cláusulas de aceptación ficta si no hay objeciones en el plazo.

Conclusión:

Los contratos informáticos son negocios jurídicos complejos que requieren una regulación y comprensión específica debido a la naturaleza de su objeto (el sistema), el desequilibrio de conocimiento entre las partes y la necesidad de colaboración y transparencia. La doctrina y la jurisprudencia han desarrollado conceptos clave como el principio de sistema, el deber de información y consejo del proveedor, el deber de colaboración y carga de definir necesidades del usuario, y garantías específicas, buscando restablecer la igualdad negocial y asegurar que el sistema entregado satisfaga los objetivos del usuario, más allá de sus especificaciones técnicas aisladas. El test de aceptación se presenta como una herramienta esencial para validar el cumplimiento de la prestación.

Derechos Intelectuales

Resumen Ejecutivo:

El documento "Clase 6 Derechos Intelectuales.pdf" explora el concepto de derechos intelectuales, diferenciándolos de los derechos reales y personales tradicionales. Analiza la regulación de estos derechos en el ordenamiento jurídico argentino a través de la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual y la Ley 22.362 de Marcas y Designaciones, con especial énfasis en la protección del software. Se detallan los derechos patrimoniales y morales del autor, los plazos de protección, los procedimientos de registro y las acciones civiles y penales contra la violación de estos derechos. Finalmente, se abordan las nociones clave sobre las licencias de uso de software, la cesión de código fuente y las características del software libre.

Temas Principales y Hechos Clave:

Concepto y Naturaleza Jurídica de los Derechos Intelectuales:

Los derechos intelectuales se refieren a las relaciones entre los frutos del trabajo intelectual (patentes, creaciones artísticas, denominaciones comerciales) y su autor.

Aunque se usa el término "propiedad", no se engloban en los derechos reales.

Se diferencian de la división tradicional de derechos subjetivos en personales y reales, establecida por Freitas e influenciada por Vélez Sarsfield.

Los derechos reales se establecen directamente entre el titular y la cosa (ej: dominio sobre un auto) y son absolutos, oponibles a terceros.

Los derechos personales vinculan a dos o más personas determinadas o determinables (acreedor y deudor) y generan efectos relativos, limitados a las partes.

Los derechos intelectuales no encajan plenamente: "En primer lugar, a diferencia de los derechos reales, el derechos intelectual no recae sobre un objeto material."

Poseen un aspecto absoluto: "este derecho a percibir las regalías debe ser respetado por cualquier tercero, siendo por tanto absoluto."

Tienen un segundo aspecto extrapatrimonial: los derechos morales.

Consisten en el reconocimiento de la autoría y la posibilidad de determinar el destino final de la obra.

Son intransmisibles y permanecen con el autor.

El autor puede modificar o retirar la obra incluso habiendo cedido los derechos patrimoniales (previa indemnización de perjuicios).

Conclusión clave: "1.- Los derechos intelectuales son una clase aparte de los derechos reales y personales. 2.- El derecho de autor tiene un doble aspecto: Uno patrimonial, referido a los derechos de explotación de la creación intelectual, y otro de naturaleza extrapatrimonial, referido a los derechos morales derivados de la obra. 3.- Mientras que los derechos patrimoniales son susceptibles de transmisión, los derechos morales permanecen con el autor de la obra."

Regulación de los Derechos Intelectuales en Argentina:

Se regulan principalmente por tres leyes:

Ley 11.723 de Propiedad Intelectual.

Ley 24.481 de Patentes de Invención (no aplicable a software según el texto).

Ley 22.362 de Marcas y Designaciones.

La regulación del software bajo el régimen de derechos de autor (Ley 11.723) es una solución extraída del common law (copyright), aunque con diferencias: "la adopción del régimen de derechos de autor para la protección del software, es una solución extraída del common law. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que su equivalente en el derecho anglosajón, el copyright, presenta algunas diferencias notorias con el derecho autoral, las cuales hacen que muchas veces las regulaciones aparezcan como forzadas o poco claras."

Ley 11.723 de Propiedad Intelectual:

Ámbito de Aplicación: Protege obras científicas, literarias y artísticas, incluyendo "los programas de computación fuente y objeto, las compilaciones de datos y otros materiales" (art. 1 modificado para incluir software).

La protección abarca la expresión de ideas, procedimientos, métodos, etc., "pero no esas ideas, procedimientos, métodos y conceptos en sí".

Requiere que la idea se exteriorice en una "producción" o elemento corpóreo y que la obra tenga cierto grado de originalidad (no se exige originalidad absoluta).

Tutela de los Derechos e Inscripción Registral: El autor tiene derecho a la explotación económica y a disponer de los derechos patrimoniales.

Siempre conserva los derechos morales.

La inscripción en el Registro Nacional de Propiedad Intelectual es necesaria para la efectividad de la protección (art. 57-63).

Se deben depositar ejemplares (tres, o uno en casos especiales como software no enlatado).

Publicación en boletín oficial para recibir oposiciones.

La inscripción tiene efectos declarativos; la falta de inscripción suspende los derechos hasta la inscripción.

Titulares del Derecho y Plazos: Titulares: el autor, sus herederos, y quienes, con permiso, traduzcan, adapten, etc., pero solo sobre la obra resultante.

El derecho de autor es vitalicio.

Los derechos de los sucesores duran 70 años desde el 1 de enero del año siguiente a la muerte del autor (art. 5).

Si el autor no tiene herederos, los derechos pasan al Estado.

Tras vencer el plazo, la obra entra en dominio público.

Autores extranjeros: Protegidos si cumplen formalidades. La protección no excede la de su país de origen ni la de la Ley 11.723 (se aplica el plazo menor). La incorporación del símbolo © junto a nombre y año de primera publicación es suficiente según la Convención de Ginebra.

Protección Civil y Penal: Penal: El que defraude derechos de propiedad intelectual enfrenta pena de 6 meses a 6 años de prisión (art. 71 y 172 C.P.). El art. 72 tipifica conductas específicas (edición o reproducción sin autorización, falsificación, modificación dolosa, exceder ejemplares convenidos). Son delitos de acción pública, no excarcelables.

Civil: Procedimiento abreviado (reglas de excepciones previas). Posibilidad de jurado técnico (no vinculante) para dictaminar sobre lesión.

Cualquier particular puede denunciar ante el registro la modificación/cercenamiento de obras en dominio público. El dictamen de expertos del registro es vinculante y puede imponer multas o secuestro.

Marcas y Denominaciones Comerciales (Ley 22.362):

Concepto: Signos característicos y distintivos que diferencian productos o servicios.

Fundamentales para la competencia en el mercado y las decisiones del consumidor.

Superan la función de identificación, constituyendo un bien económicamente valioso ("La publicidad y el marketing generan una asociación entre una determinada marca y un grupo de valores o aspiraciones sociales que permiten una mejor comercialización").

Protegen los signos distintivos del software como producto comercial.

Clasificaciones: De productos (Clases 1-34) y de servicios (Clases 35-42).

Registradas o de hecho (solo las registradas tienen protección legal, salvo notorias).

Originales y de defensa.

Régimen Aplicable: Concepto de marca (art. 1): Amplio, incluye palabras, dibujos, emblemas, monogramas, etc. "cualquier otro signo con capacidad distintiva." La enumeración no es taxativa.

Limitaciones (art. 2 y 3): No pueden ser marca características habituales del producto, nombres genéricos, cualidades, formas, colores de uso general, denominaciones de origen, expresiones engañosas o reservadas a entes públicos.

Adquisición del derecho e Inscripción: La propiedad y exclusividad se adquieren con la inscripción registral, que tiene carácter constitutivo (art. 4). Excepción para marcas notorias.

La inscripción se realiza en categorías preestablecidas, permitiendo que una misma marca identifique productos/servicios diferentes en distintas clases.

Procedimiento de registro (solicitud por clase, publicación en Boletín de Marcas, examen, oposiciones). La Dirección Nacional de Propiedad Industrial puede denegar la inscripción, apelable judicialmente.

Lapso de Duración y Marcas de Defensa: Duración: 10 años, prorrogable indefinidamente si se demuestra uso en al menos una categoría.

Marcas de defensa: Inscriptas en categorías diferentes a las del uso principal. Su función es evitar la disolución de marca ("evitar que la marca original se diluya, mediante la proliferación de productos de igual nombre en otras rubros"). Impiden el registro por terceros y limitan la confusión en rubros conexos.

Protección Civil y Penal: Penal (art. 31): Penas de 3 meses a 2 años por falsificar, usar sin autorización o comercializar marcas registradas falsificadas o sin autorización.

Delitos de acción pública.

Civil: Juicio ordinario ante justicia federal para cesación del uso no autorizado.

En ambos casos, se puede solicitar el secuestro de mercadería infractora. El régimen de medidas precautorias es más accesible que en propiedad intelectual, lo que lo hace útil para el secuestro de copias ilegales de software.

Defensa Jurídica del Software (bajo Ley 11.723):

La protección del software por la Ley 11.723 es relativamente reciente.

Existía debate sobre si el art. 1 original lo incluía o si se necesitaba legislación expresa.

Hasta 1997, prevaleció la idea de inclusión vía reglamentación (Decreto 165/94).

El fallo "Autodesk" (Corte Suprema, 1997) determinó que la venta de software sin licencia (piratería) no era delito, ya que un decreto no podía ampliar los bienes protegidos por ley ("la reglamentación de una ley... no podía ampliar los bienes protegidos por una ley... toda vez que ello implicaba una modificación a la misma.").

Este fallo motivó la modificación del art. 1 de la Ley 11.723 para incluir expresamente el software y las bases de datos.

La inclusión en la ley de derechos de autor se alinea con el acuerdo TRIPS ("los programas de ordenador... serán protegidos como obras literarias según el convenio de Berna.") y el copyright anglosajón, aunque la similitud no es total.

La elección de este régimen fue criticada por considerarse que el instituto de derechos de autor, pensado para creaciones artísticas/científicas, podía ser excesivo para el software ("el instituto fue concebido tradicionalmente... como un mecanismo de defensa de los derechos de las creaciones científicas y particularmente artísticas: Así, la existencia de derechos e incluso el lapso de protección de los derechos durante setenta años aparece como exagerado o por lo menos de dudosa aplicación directa a una obra como el software, que tiene más puntos de contacto con un producto comercial que con una expresión de la individualidad de su actor.").

La protección procesal bajo la Ley 11.723 se considera a veces deficiente, siendo el registro de la marca del software una vía complementaria útil para el secuestro de copias ilegales.

Nociones sobre Licencias de Uso, Cesión de Código Fuente y Software Libre:

Licencia de uso: Contrato por el cual el titular de derechos intelectuales sobre un programa transfiere su uso y goce al licenciatario, pero conserva la titularidad. Se prohíbe la reproducción (salvo copia de seguridad) y la retroingeniería. El licenciante suele asumir mantenimiento.

Cesión de código fuente: Se transfiere no solo el uso sino el código fuente original. Otorga al cesionario la capacidad de modificar y recompilar el programa. El autor pierde control sobre su destino.

Software libre: No implica libertad absoluta de uso. El usuario acepta una licencia general de uso con derechos y obligaciones.

A diferencia del dominio público, impide la comercialización de los desarrollos bajo el sistema (solo se pueden cobrar costos de distribución física).

Característica fundamental: obligación de poner el código fuente disponible para cualquier usuario, permitiendo modificaciones y redistribuciones. "De esta manera, el software libre se convierte en una creación colectiva..."

Citas Clave:

"Los derechos intelectuales son una clase aparte de los derechos reales y personales."

"El derecho de autor tiene un doble aspecto: Uno patrimonial... y otro de naturaleza extrapatrimonial, referido a los derechos morales derivados de la obra."

"Mientras que los derechos patrimoniales son susceptibles de transmisión, los derechos morales permanecen con el autor de la obra."

"la adopción del régimen de derechos de autor para la protección del software, es una solución extraída del common law."

"La protección de los derechos de autor abarcará la expresión de ideas, procedimientos, métodos de operación y conceptos matemáticos pero no esas ideas, procedimientos, métodos y conceptos en sí" (citando art. 1, Ley 11.723).

"la propiedad de una marca y su exclusividad se otorgan con la inscripción." (citando art. 4, Ley 22.362).

"las marcas comerciales constituyen un valor en si mismo toda vez que se relacionan con ciertos valores impulsados desde el marketing."

"...la reglamentación de una ley... no podía ampliar los bienes protegidos por una ley... toda vez que ello implicaba una modificación a la misma." (fundamento del fallo Autodesk).

"los programas de ordenador... serán protegidos como obras literarias según el convenio de Berna." (citando acuerdo TRIPS).

"La característica fundamental del software libre es la obligación de todos los desarrolladores de poner disponible el código fuente a cualquier usuario que así lo solicite..."

Implicaciones/Notas Adicionales:

La protección del software en Argentina es un reflejo de la adaptación de un marco legal tradicional (derechos de autor) a las nuevas tecnologías, influenciado por el derecho comparado.

El régimen de marcas ofrece una vía complementaria y a veces más ágil para la defensa jurídica del software, particularmente en lo que respecta a medidas precautorias y secuestro de copias ilegales.

Las diferencias entre licencia de uso, cesión de código fuente y software libre determinan el grado de control del autor sobre su creación y las posibilidades de desarrollo y modificación por parte del usuario/cesionario.

El concepto de "marcas de defensa" resalta la importancia económica y de posicionamiento de las marcas, más allá de la simple identificación del producto principal.

Voto Electrónico

Resumen Ejecutivo:

El presente documento ofrece un análisis de los elementos esenciales para una teoría general del voto electrónico, basándose en un fallo reciente del Tribunal Constitucional Alemán y en principios jurídicos fundamentales. Se argumenta que el debate sobre el voto electrónico ha sido a menudo superficial y que es necesario un marco conceptual

claro, distinguiendo entre diferentes tipos de sistemas y los requisitos jurídicos mínimos que deben cumplir para garantizar la validez y la pureza del sufragio. Se clasifican los sistemas de voto electrónico en remotos y presenciales, analizando sus problemáticas específicas, con un enfoque particular en la identificación del votante, el secreto del voto, la transparencia, la seguridad y la auditabilidad del sistema.

Temas Principales y Puntos Clave:

La Necesidad de un Marco Teórico para el Voto Electrónico:

El debate sobre el voto electrónico a menudo se basa en preconceptos a favor o en contra y trata los sistemas como una entidad monolítica, sin considerar las características específicas de cada uno.

Existe una ausencia de vocabulario jurídico para conceptualizar el tema, con la mayoría de los trabajos enfocándose en aspectos técnicos sin considerar sus efectos legales.

El trabajo busca establecer una tipología de mecanismos de registro de votación y los requisitos mínimos que un sistema de voto electrónico debe cumplir desde un punto de vista jurídico.

El Concepto de Sufragio y sus Requisitos Fundamentales:

Desde el punto de vista jurídico, el sufragio político es la actividad de emitir el voto y constituye un acto político, relacionado con la formación de la voluntad del estado.

Históricamente, el sufragio se fundamenta en la voluntad de los individuos, en contraposición a teorías teológicas del poder del estado. La democracia moderna amplía la participación popular a través del sufragio.

Para que el resultado del sufragio sea la expresión de la voluntad de la comunidad, la votación debe garantizar ciertos requisitos mínimos. La Convención de las Naciones Unidas en derechos civiles y políticos (art. 25 inciso b) y la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 23) establecen estos requisitos:

Universalidad: Todos los ciudadanos deben ser titulares de derechos electorales, sin limitaciones o discriminaciones arbitrarias.

Igualdad: Los derechos electorales de todos los ciudadanos deben ser similares, excluyendo el "voto calificado".

Secreto: El voto debe emitirse de forma que se asegure la confidencialidad del sufragante. El secreto del sufragio es una condición necesaria para asegurar la inexistencia de vicios sobre el consentimiento del votante.

Estos requisitos son comunes a todos los sistemas de sufragio, incluyendo los sistemas de voto electrónico. La recomendación REC (2004) 11 del Comité de Ministros de la Unión Europea reconoce la necesidad de respetarlos.

Concepto y Clasificación del Voto Electrónico:

La novedad del voto electrónico reside en la digitalización del acto electoral en sí, ya sea en el momento del recuento o de la emisión del voto.

El principal efecto jurídico es la eliminación del paso entre la manifestación de la voluntad del elector y su registro.

Los sistemas de voto electrónico pueden clasificarse en:

Sistemas Presenciales: Implican la concurrencia obligatoria a un lugar determinado por el estado. Existe inmediatez entre el votante y la autoridad estatal.

Sistemas Remotos: Permiten la emisión del sufragio desde lugares no habilitados específicamente, como el hogar, utilizando medios telemáticos (Internet, telefonía).

Problemáticas de los Sistemas de Votación Remotos:

La principal característica jurídica es la separación física entre la autoridad de votación y el emisor del voto.

Problema de Identidad ("The doorkeeper principle"): Es imposible asegurar la identidad entre el votante y el titular del derecho sin la presencia física de la autoridad.

Los métodos de identificación remota (tarjetas, claves) carecen de la seguridad necesaria. La utilización de métodos de clave única permitiría la suplantación de votantes.

Problema de Confidencialidad y Consentimiento: Coacción del votante: Al trasladar el lugar de votación al hogar, es imposible controlar las condiciones en que se emite el voto sin violar el principio de inviolabilidad de domicilio. Los métodos tradicionales en lugares controlados ofrecen garantías especiales.

Almacenamiento y Transmisión de Datos: El estado actual de la tecnología no garantiza una comunicación cien por cien segura. Existe la posibilidad de interferir en el tránsito de los mensajes o manipular los sistemas. El uso de ordenadores de propiedad de los electores para emitir el voto impide la fiscalización por parte del estado.

Análisis de los Sistemas de Votación Presenciales:

Implican la presencia física del elector en un espacio determinado y la inmediatez con la autoridad estatal.

Se pueden diferenciar dos grandes grupos:

Sistemas de Lectura Óptica de Voto: No modifican sustancialmente la forma de emisión (soporte papel), digitalizando el cómputo. El soporte papel sirve como comprobante y testigo para auditorías. La principal ventaja es la conservación de métodos tradicionales; la desventaja, la posibilidad de errores en la lectura que modifiquen la voluntad manifestada.

Sistemas de Registro Electrónico Directo (RED): El acto del sufragio se descorporiza y la voluntad del elector se almacena digitalmente en la máquina de votación. La mayoría de los sistemas modernos adoptan este método por menor costo y facilidad logística. La principal crítica es la ausencia de capacidad para auditar el sistema y el resultado por parte del elector y el estado, lo que plantea interrogantes sobre la seguridad y la correspondencia entre la manifestación de voluntad y el registro.

Requisitos de los Sistemas de Votación Electrónica (enfoque en Sistemas Presenciales RED):

Basado en el fallo del Tribunal Constitucional Alemán y la recomendación 11/04 de la UE, los requisitos clave son:

Transparencia: Posibilidad de los ciudadanos de conocer y analizar los sistemas.

Requiere acceso a las características técnicas, superando la reticencia de las empresas desarrolladoras por secreto comercial. La publicidad de las características técnicas es necesaria para asegurar la confianza pública y cumplir con los requisitos

del sufragio (seguridad, secreto). El sistema debe evitar mecanismos que generen un registro histórico de votos emitidos que permita vincular un voto a un elector (ejemplo del time stamp en sistemas antiguos de Ohio). El acceso al código fuente es crucial para controlar estas operaciones. La posibilidad de control por parte de los partidos políticos o incluso el libre acceso al código fuente (bajo licencias no propietarias) es objeto de debate, aunque el fallo alemán no exige el libre acceso para todos los ciudadanos, considerando suficiente el control limitado a actores autorizados. La capacidad de controlar el código fuente requiere conocimiento técnico, lo que limita la efectividad del libre acceso para la mayoría de la población.

Seguridad: Mecanismos para evitar cómputos erróneos (por elector o sistema) y ataques externos o código malicioso. A diferencia de los sistemas bancarios, los sistemas de voto RED no pueden dejar un rastro auditable de operaciones sin violar el secreto. La falta de reaseguros en la interfaz puede llevar a la nulidad de votos (ejemplo de Florida en 2000). Numerosos análisis de sistemas (Diebold, Nedap, ES&S) han detectado graves deficiencias de seguridad. La regulación de la seguridad a menudo se relega a normativas reglamentarias para asegurar la neutralidad tecnológica de la ley electoral.

Auditabilidad: Capacidad de analizar o controlar los resultados de la votación después de finalizada. Fundamental en sistemas RED por la intangibilidad del voto. El control debe ser posible para cualquier persona, independientemente de sus conocimientos informáticos.

Fallo Alemán (considerando 112): Sostiene que un proceso electoral donde los electores no puedan comprender de manera confiable cómo se registra su voto y se cuentan los resultados "excluye el control público de los elementos procedimentales de la elección y por ello no basta los requisitos del derecho constitucional".

Soluciones para la Auditabilidad: La emisión de un comprobante en papel visto por el votante (paper trail propuesto por Rebecca Mercuri) es vista como necesaria. Las soluciones basadas en la duplicación de sistemas de almacenamiento no ofrecen las seguridades necesarias ya que solo reflejan el cómputo de la máquina, no la voluntad del votante, y requieren conocimiento especializado para su análisis. La doctrina apoya mayoritariamente la existencia de comprobantes en papel.

El fallo alemán (acápito 121) no invalida per se la norma que establece un sistema de voto electrónico siempre que permita el control por parte del votante, mencionando el paper trail o el registro óptico como soluciones posibles.

Conclusiones (según el autor):

El acto del sufragio constituye un acto de gobierno fundamental que debe cumplir requisitos básicos.

Las soluciones basadas en sistemas remotos de votación deben ser rechazadas debido a la falta de seguridad (especialmente en identidad y secreto).

Respecto a los sistemas de registro electrónico directo (RED), es necesario establecer la auditabilidad del sistema por parte del votante (implica la necesidad de un comprobante verificable por el elector).

Recomendaciones Implícitas / Áreas para Mayor Consideración:

Es crucial desarrollar un vocabulario jurídico preciso para el voto electrónico.

La legislación electoral debe establecer requisitos mínimos claros para los sistemas de voto electrónico, asegurando universalidad, igualdad, secreto, transparencia, seguridad y auditabilidad.

Los sistemas de voto remoto presentan desafíos significativos para cumplir con los principios fundamentales del sufragio, particularmente en la identificación y el secreto.

En los sistemas presenciales RED, la transparencia (incluido el acceso al código fuente para actores relevantes) y, fundamentalmente, la auditabilidad verificable por el votante (como el paper trail) son elementos esenciales para la validez constitucional.

La seguridad de los sistemas electrónicos requiere análisis técnicos rigurosos e independientes.